RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 1.628.735 SÃO PAULO

RELATOR	**: MIN. LUIZ FUX**
RECTE.(S)	: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
PROC.(A/S)(ES)	: PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
RECDO.(A/S)	: KAIQUE SILVA DOS ANJOS
PROC.(A/S)(ES)	: DEFENSOR PÚBLICO-GERAL DO ESTADO DE SÃO PAULO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPERCENTES. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, XLIII E XLVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRETENDIDO RECONHECIMENTO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA MINORANTE PREVISTA NO § 4º DO ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006. OFENSA REFLEXA AO TEXTO CONSTITUCIONAL. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CARREADO AOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO DESPROVIDO.

DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea *a* do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou, *in verbis*:

> AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DECISÃO UNIPESSOAL DO RELATOR. PREVISÃO REGIMENTAL E SUMULADA.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código E543-67B8-51B3-862A e senha 37F8-A050-090B-9A47

> JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA PELAS CORTES SUPERIORES. MINORANTE PREVISTA NO ART. 33, § 4º DA LEI DE DROGAS. CONCESSÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. O avanço para julgamento in limine de questões pacificadas pelo colegiado – com lastro no art. 34, XVIII, "c", e XX, do Regimento Interno deste Superior Tribunal, e no enunciado n. 568 da Súmula desta Corte de Justiça – está em consonância com o princípio da efetiva entrega da prestação jurisdicional e visa a otimizar o processo e seus atos, para viabilizar sua razoável duração e a concentração de esforços em lides não iterativas. 2. A prolação de decisum, liminarmente, antes do parecer do Ministério Público Federal, é admitida pelos Tribunais Superiores, quando se reconhece flagrante ilegalidade sobre a qual haja repisada jurisprudência. De todo modo, a remessa dos autos para manifestação do Parquet, como fiscal da lei, sempre ocorre, ainda que posteriormente, com possibilidade de interposição do recurso cabível ao colegiado. 3. No que tange ao quantum de redução de pena pela minorante do tráfico, faço lembrar que tanto a Quinta quanto a Sexta Turma deste Superior Tribunal firmaram o entendimento de que, considerando que o legislador não estabeleceu especificamente os parâmetros para a escolha da fração de redução de pena, devem ser orientadoras do cálculo da minorante as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, especialmente o disposto no art. 42 da Lei de Drogas. 4. A fração de 2/3 é adequada ao caso concreto, pois a mera menção ao objetivo de lucro, que é inerente ao delito de tráfico, e a recusa do réu em revelar supostos envolvidos no esquema criminosa, não são elementos idôneos para modulação do redutor. 5. Agravo regimental não provido.

Opostos embargos de declaração, foram acolhidos, sem efeitos infringentes, conforme ementa:

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código E543-67B8-51B3-862A e senha 37F8-A050-090B-9A47

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. ERRO MATERIAL. AFASTAMENTO DA MINORANTE PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006 PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. FUNDAMENTOS INIDÔNEOS. DIREITO AO SILÊNCIO. VEDAÇÃO AO BIS IN IDEM. AUSÊNCIA DE EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS. 1. O erro material pode ser corrigido em embargos de declaração quando verificada premissa fática equivocada no julgado, sem necessidade de modificação do resultado anteriormente proclamado. 2. No caso, constata-se que o acórdão embargado partiu da premissa equivocada de que o Tribunal de origem teria mantido a minorante do tráfico privilegiado no patamar de 1/6, quando, em verdade, a Corte estadual afastou integralmente a causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006. 3. O direito ao silêncio constitui garantia fundamental assegurada pelo art. 5 º, LXIII, da Constituição Federal, não podendo a recusa do acusado em revelar eventuais comparsas ou corroborar a versão acusatória ser valorada em seu desfavor para afastar a minorante do tráfico privilegiado. 4. O lucro auferido com a atividade delitiva constitui elemento inerente ao tipo penal do tráfico de drogas, de modo que sua utilização para afastar ou reduzir a minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 configura bis in idem. 5. A ausência de elementos concretos aptos a demonstrar dedicação habitual a atividades criminosas ou integração a organização criminosa impede o afastamento da minorante do tráfico privilegiado. 6. A correção do erro material não altera o resultado do julgamento, pois os fundamentos utilizados pela instância de origem revelam-se igualmente inidôneos para afastar a minorante, mantida a concessão da ordem com aplicação do redutor no patamar máximo de 2/3. 7. Embargos de declaração acolhidos, tão somente para corrigir erro material, sem efeitos infringentes, mantidos os exatos termos do

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código E543-67B8-51B3-862A e senha 37F8-A050-090B-9A47

julgamento anteriormente proferido.

Nas razões do apelo extremo, o recorrente sustenta preliminar de Repercussão Geral e, no mérito, aponta violação ao artigo 5º, XLIII e XLVI, da Constituição Federal.

A parte recorrente narra que *"Em habeas corpus impetrado em favor de Kaique Silva dos Anjos, o Superior Tribunal de Justiça concedeu a ordem, por decisão monocrática, para aplicar o redutor do tráfico privilegiado na fração de 2/3, readequando a reprimenda final do paciente para 2 anos e 4 meses de reclusão, 233 dias-multa, em regime inicial semiaberto. Mantida a decisão no agravo regimental interposto pelo Ministério Público, foram opostos embargos de declaração, acolhidos tão somente para corrigir erro material: o acórdão embargado partira da premissa equivocada de que o Tribunal de origem teria fixado a minorante no patamar de 1/6, quando, em verdade, a Corte estadual a afastara integralmente."*

Acrescenta que *"o agravado foi preso em flagrante, processado e condenado, porque no dia 23 de dezembro de 2024, por volta das 15 horas e 30 minutos, na Rua Aldo José de Souza, Residencial Tatetuba, na comarca de São José dos Campos, transportava, com destinação mercantil e para entrega a consumo de terceiros, aproximadamente sete quilogramas de cocaína, distribuída em sete tijolos, os quais foram acondicionados em caixa de som de madeira no porta-malas do veículo."*

Sustenta, em síntese, que *"A análise da impetração, à luz dos documentos apresentados, permite concluir que a quantidade e nocividade das drogas foram idoneamente valoradas pelo acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo em apenas uma etapa da dosimetria da pena e, observadas as demais circunstâncias da prática delitiva, como a expressiva quantidade de cocaína apreendida (aproximadamente sete quilogramas), o modus operandi profissional com ocultamento da droga em caixa de som, o envolvimento com esquema organizado de distribuição e a preservação deliberada das fontes de fornecimento, foi corretamente afastada a causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4º, da*

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código E543-67B8-51B3-862A e senha 37F8-A050-090B-9A47

Lei nº 11.343/2006.".

Aduz que *"optou o Superior Tribunal de Justiça por revalorar os elementos fáticos que sustentavam o afastamento da minorante, consistentes na ocultação deliberada do esquema criminoso e o envolvimento em estrutura profissional de distribuição de entorpecentes em larga escala, concluindo, em sentido contrário ao do Tribunal de origem, pela ausência de dedicação habitual à atividade delitiva."*

Pontua que *"Em se tratando de tráfico ilícito de tantas drogas de forma organizada - aproximadamente sete quilogramas de cocaína, distribuídos em sete tijolos, acondicionados em caixa de som de madeira no porta-malas do veículo, a demonstrar especial preparação e cenário de profissionalismo nesse transporte não eventual e isolado, portanto, além de R$ 340,00, por agente que ocultou deliberadamente o esquema de distribuição do qual fazia parte, preservando as fontes de fornecimento e desempenhando tarefa relevante em estrutura profissional de narcotraficância -, a demonstrar suficientemente a dedicação ao tráfico de drogas o que é incompatível com a mera traficância eventual (é impossível obter todas essas drogas e estruturar o narcotráfico desta forma sem integrar hierarquia compatível ou já ter a confiança dos narcotraficantes responsáveis pelo fornecimento), a sanção penal resultante da decisão monocrática agravada violou a proporcionalidade, a proibição da proteção jurídica deficiente e impede a consecução de todas as finalidades da pena, devendo ser reformada para afastar a aplicação do redutor do § 4º do artigo 33 da Lei n. 11.343/2006."*

Salienta que *"o posicionamento adotado no acórdão combatido viola o artigo 5º, incisos XLIII e XLVI, da Constituição Federal, ao frustrar a correta individualização da pena no processo penal na fase de conhecimento, aplicando pena insuficiente, em incidência na proibição de proteção jurídica deficiente, e ao frustrar a efetividade da repressão e prevenção ao narcotráfico, que é infração penal alçada pela Constituição Federal como paradigma para a legislação infraconstitucional que prevê os crimes hediondos a ela equiparados, que diversamente do tráfico ilícito de drogas, não tiveram disposição expressa específica constitucional."*

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código E543-67B8-51B3-862A e senha 37F8-A050-090B-9A47

A Corte *a quo* não admitiu o apelo extremo, por entender que a controvérsia é de índole infraconstitucional.

É o relatório. **DECIDO**.

O agravo não merece prosperar.

De fato, verifica-se que a resolução da controvérsia atinente à incidência ou não da minorante prevista no § 4º do artigo 33 da Lei 11.343/2006, demandaria a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei 11.343/2006), o que se revela inviável em sede de recurso extraordinário, por configurar ofensa indireta à Constituição Federal. Nesse sentido, confira-se o ARE 1.055.410-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, *DJe* de 21/11/2017, o qual possui a seguinte ementa:

> *"AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ALEGADA AFRONTA AO ART. 5º, XLVI E XLVIII, DA MAGNA CARTA. PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA REPRIMENDA. TEMAS SITUADOS NO CONTEXTO NORMATIVO INFRACONSTITUCIONAL. INVIABILIDADE DE REEXAME PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. 1.* ***Nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a alegação de afronta ao princípio da individualização das penas configura matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as ofensas à Constituição indicadas no recurso extraordinário são meramente indiretas*** *(ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. Precedentes. 2. Há precedentes de ambas as Turmas desta Corte no sentido de que a revisão dos critérios utilizados para a fixação do regime inicial de cumprimento da pena exige o incursionamento nos fatos e provas concernentes à causa, o que encontra óbice na Súmula 279 do STF. 3. Agravo interno a que se nega provimento."* (Grifei)

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código E543-67B8-51B3-862A e senha 37F8-A050-090B-9A47

In casu, o Tribunal *a quo* assentou que:

> *"De todo modo, a despeito das alegações ministeriais, noto que o decisum combatido foi claro ao demonstrar a necessidade de reconhecimento da minorante descrita no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 no patamar máximo.*
>
> *(...)*
>
> *Assim, observa-se que o dispositivo legal traz apenas os requisitos necessários para a aplicação da minorante nele prevista; deixa, contudo, de estabelecer os parâmetros para a fixação do quantum de diminuição de pena.*
>
> *Nesse sentido, tanto a Quinta quanto a Sexta Turmas deste Superior Tribunal firmaram o entendimento de que, tendo em vista que o legislador não estabeleceu especificamente os parâmetros para a escolha da fração de redução de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, devem ser consideradas, para orientar o cálculo da minorante, as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, especialmente o disposto no art. 42 da Lei de Drogas.*
>
> *Veja-se, portanto, que o Tribunal de origem fundamentou a aplicação do privilégio previsto no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas na fração de 1/6, por haver o réu ocultado "o esquema do qual realizava tarefa relevante" (fl. 59) e o lucro auferido com tal tarefa.*
>
> *Entendo, entretanto, que tais fundamentos revelam-se inidôneos, pois, além de ser o lucro inerente ao delito de tráfico, o direito ao silêncio constitui garantia fundamental do acusado e a fruição desse direito não pode ser interpretada em prejuízo do réu."*

Ao julgar os embargos de declaração, a Corte Superior consignou que:

> *"Assiste razão à embargante quanto ao erro material apontado.*

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código E543-67B8-51B3-862A e senha 37F8-A050-090B-9A47

Com efeito, a análise do acórdão embargado (fls. 59-60) revela que o Tribunal de origem não fixou a minorante no patamar de 1/6, como consignado na decisão ora embargada. Na verdade, a Corte estadual afastou integralmente a causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006.

(...)

A correção do erro material, contudo, não altera o resultado do julgamento, pois os fundamentos utilizados pelo Tribunal de origem para afastar a minorante são igualmente inidôneos.

Com efeito, a Corte estadual apoiou-se em dois fundamentos centrais para afastar a minorante: a) o fato de o paciente haver ocultado deliberadamente o esquema criminoso, com versão tida por inverossímil; e b) o lucro auferido com a atividade delitiva.

Quanto ao primeiro fundamento, esclareço que o direito ao silêncio constitui garantia fundamental, assegurada pelo art. 5º, LXIII, da Constituição Federal. A fruição dessa prerrogativa não pode ser valorada em desfavor do acusado, sob pena de nulificar-se a própria garantia. A recusa em revelar eventuais comparsas ou em confirmar a versão acusatória não configura, por si só, indicativo de dedicação habitual à atividade criminosa, tampouco de integração a organização criminosa – elementos que, esses sim, poderiam legitimar o afastamento da minorante. A colaboração com as investigações ou a delação de envolvidos não integra o rol de requisitos previstos no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006.

Quanto ao lucro obtido com o tráfico, cuida-se de elemento inerente ao próprio tipo penal. O delito de tráfico ilícito de drogas é, por natureza, praticado com finalidade lucrativa. Utilizá-lo como fundamento autônomo para afastar ou reduzir a minorante implica valorar negativamente circunstância já contemplada na própria tipificação do crime, o que viola a vedação ao bis in idem.

A instância de origem, portanto, não indicou nenhum elemento concreto dos autos que evidenciasse, de modo robusto, a real dedicação

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código E543-67B8-51B3-862A e senha 37F8-A050-090B-9A47

> *do paciente às atividades criminosas ou sua integração a organização criminosa."*

Ademais, não se revela cognoscível, em sede de recurso extraordinário, a insurgência que tem como escopo a incursão no contexto fático-probatório presente nos autos, revelada pelas alegações de que:

> *"Em se tratando de tráfico ilícito de tantas drogas de forma organizada - aproximadamente sete quilogramas de cocaína, distribuídos em sete tijolos, acondicionados em caixa de som de madeira no porta-malas do veículo, a demonstrar especial preparação e cenário de profissionalismo nesse transporte não eventual e isolado, portanto, além de R$ 340,00, por agente que ocultou deliberadamente o esquema de distribuição do qual fazia parte, preservando as fontes de fornecimento e desempenhando tarefa relevante em estrutura profissional de narcotraficância -, a demonstrar suficientemente a dedicação ao tráfico de drogas o que é incompatível com a mera traficância eventual (é impossível obter todas essas drogas e estruturar o narcotráfico desta forma sem integrar hierarquia compatível ou já ter a confiança dos narcotraficantes responsáveis pelo fornecimento), a sanção penal resultante da decisão monocrática agravada violou a proporcionalidade, a proibição da proteção jurídica deficiente e impede a consecução de todas as finalidades da pena, devendo ser reformada para afastar a aplicação do redutor do § 4º do artigo 33 da Lei n. 11.343/2006."*

Com efeito, essa pretensão não se amolda à estreita via do apelo extremo, cujo conteúdo se restringe a discussão eminentemente de direito, em face do óbice imposto pela Súmula 279 do STF, que dispõe: "*Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário*". Nesse sentido, aliás, é a jurisprudência desta Corte:

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código E543-67B8-51B3-862A e senha 37F8-A050-090B-9A47

> *"AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL.* ***TRÁFICO DE DROGAS. MINORANTE PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006.*** *REGIME INICIAL. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. RAZÕES DO AGRAVO REGIMENTAL DISSOCIADAS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284 DO STF.* ***REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DA CORTE.*** *AGRAVO DESPROVIDO. 1. As razões do agravo regimental encontram-se dissociadas dos fundamentos utilizados pela decisão agravada, o que atrai a incidência da Súmula 284 do STF. Precedentes. 2.* ***Eventual divergência em relação ao entendimento proferido pelo Tribunal de origem demandaria o reexame dos fatos e provas constantes dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista o óbice contido na Súmula 279 desta Corte****. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento*." (ARE 1.402.367-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 17/2/2023)

Sob esse enfoque, ressoa inequívoca a vocação para o insucesso do apelo extremo, por força do óbice intransponível do referido verbete sumular, que veda a esta Suprema Corte, em sede de recurso extraordinário, sindicar matéria fática.

Consectariamente, forçoso é concluir que, à luz do entendimento jurisprudencial desta Corte, o recurso extraordinário a que se refere o presente agravo revela-se inadmissível.

Ex positis, **NEGO PROVIMENTO** ao agravo, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF.

Publique-se.

Brasília, 27 de outubro de 2026.

Ministro LUIZ FUX

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código E543-67B8-51B3-862A e senha 37F8-A050-090B-9A47

Relator

Documento assinado digitalmente

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código E543-67B8-51B3-862A e senha 37F8-A050-090B-9A47